

1500651-53.2022.8.26.0594
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Érica Marcelina Cruz
Comarca: Bauru
Foro: Foro de Bauru
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/11/2022
... falar qualquer ilegalidade. Nesse sentido:

"TRÁFICO DE DROGAS RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL NULIDADE INOCORRÊNCIA PRESENTE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO DOS POLICIAIS HIPÓTESE DE FLAGRANTE PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. TRÁFICO DE DROGAS RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INADMISSIBILIDADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bauru
Foro de Bauru
1ª Vara Criminal
Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500651-53.2022.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500651-53.2022.8.26.0594
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161019/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 25543600 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2161019 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FERNANDO LUIZ PEREIRA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

FERNANDO LUIZ PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta da denúncia, o acusado, no dia 13 de junho de 2022, às 18h, na Rua Joaquim de Barros Neto, quadra 02, no bairro Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima, nesta cidade e comarca de Barú-SP, foi surpreendido com 236,71 gramas de maconha, 4,28 gramas de crack e 2,90 gramas de cocaína, para fins de tráfico.

Auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de

exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo definitivo (fls. 144/148).

Às fls. 89/91 foi determinada a notificação do réu para que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06, oferecesse defesa prévia, por escrito, no prazo de dez dias. Na mesma oportunidade, a denúncia foi recebida em 27 de junho de 2022.

O acusado foi notificado (fls.102) e apresentou defesa prévia (fls.106).

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 05 de outubro de 2022, foram colhidos os depoimentos das testemunhas comuns. O réu foi interrogado (fls. 138/140).

Em sede de memoriais, o Ministério Público pediu, em resumo, a procedência da ação penal, com a consequente condenação do acusado. Apontou que os policiais confirmaram os fatos descritos na exordial acusatória. Sustentou que corroboram a condenação os seguintes documentos: auto de prisão (fls.04), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls.16/17), laudo de constatação (fls.18/27), laudo de exame químico toxicológico (fls.144/148) e relatório policial (fls.77/78). Entendeu que a autoria e materialidade foram demonstradas. Explicou que são válidas as palavras dos policiais militares. Pediu a condenação do réu. Defendeu que não é cabível a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006. Sugeriu a pena de 07 anos de reclusão e pagamento de multa. Pugnou pela fixação do regime fechado (fls. 152/158).

A D. Defesa, por sua vez, em síntese, buscou a improcedência da ação penal, com a correlata absolvição do acusado, eis que a pretensão acusatória não deve prosperar, pois o conjunto probatório não é suficiente para alicerçar o edito condenatório. Asseverou que a abordagem policial do acusado foi ilegal, eis que foi baseada apenas no suposto "nervosismo" apresentado pelo réu, o que viola o art. 244, do CPP. Ressaltou que o Colendo STJ entende que é ilegal a busca pessoal sem mandado judicial. Sustentou que deve ser reconhecida a ilegalidade da abordagem policial, o que macula as provas produzidas. Salientou que não foram ouvidas, como testemunhas, pessoas que estavam presentes no momento dos fatos. Requereu a absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do CPP. De forma subsidiária, pediu a fixação da pena base no mínimo legal. Na segunda fase, defendeu o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Pediu a fixação do regime semiaberto (fls. 162/164).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente, pelos fundamentos a seguir elencados.

A materialidade do delito veio demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo definitivo (fls. 144/148).

Quanto à autoria, é certa.

Vejamos.

Em juízo, a testemunha policial militar Rodrigo Fernandes Martins disse, em resumo, que estavam em patrulhamento, quando avistaram o acusado com "as mãos na cintura e volume no bolso". O réu demonstrou 'nervosismo', razão pela qual a equipe policial realizou a abordagem. Durante a busca pessoal, encontraram uma sacola que continha drogas diversas, tais como "crack", cocaína e maconha, ou seja, 36 pedras de "crack", 10 porções de cocaína e 17 porções de maconha. Apreenderam quantia em dinheiro. O réu, em entrevista pessoal, declarou que 'fazia o comércio de drogas

nas imediações e indicou outro local'. No local indicado, debaixo de uma pedra, encontraram outra sacola que continha o valor de R\$ 440,00, distribuída em notas diversas e 11 porções maiores de maconha. Foi dada voz de prisão contra o réu. Não conhecia o acusado do meio policial. Não sabe se o réu residia nas proximidades. O réu estava sentado na calçada. O réu estava defronte a uma árvore. Não realizaram campanas, eis que a abordagem foi imediata. O réu estava com "volume aparente no bolso", o que motivou a abordagem. No local, havia transeuntes e moradores. Os moradores eram transeuntes e não foram arroladas como testemunhas (fls. 138/140).

Na mesma toada, em juízo, a testemunha policial militar Leandro Valentim Alves contou, em síntese, que estavam em patrulhamento, quando viram o réu na calçada, "com a mão no bolso". O réu trajava uma "blusa de frio". Em busca pessoal, encontraram drogas e dinheiro, no bolso do acusado. Numa árvore, havia uma pedra. Debaixo da pedra, havia um buraco, onde estava acondicionada embalagem que continha mais entorpecentes e dinheiro. O réu declarou que realizava o comércio de drogas. O réu explicou que saiu da unidade prisional e comercializava drogas. O réu declarou que auferia renda média de mil reais, por dia. O réu foi encaminhado à delegacia. Não conhecia o réu de outras abordagens. O réu estava a uma distância aproximada de um ou dois metros da árvore. O réu estava em poder de R\$ 120,00. O réu estava na esquina, "com as mãos no bolso e de pé". O local era uma "rua muito movimentada". Não deu tempo para o acusado se evadir (fls. 138/140).

No interrogatório judicial, o réu Fernando Luiz Pereira declarou, de forma abreviada, que caminhava pela via pública, acompanhado de outra pessoa, quando foi surpreendido pelos policiais. Os policiais lhe perguntaram "quem eram os traficantes da vila?". Em seguida, eles mencionaram que: "se você não indicar os traficantes da vila, faremos uma surpresinha para você". Respondeu que não conhecia os traficantes e que fazia três meses que estava em liberdade. Os agentes de segurança afirmaram que: "se você não falar, vai ter uma surpresa". Os policiais foram até a viatura e abriram o porta-luvas. Os policiais "puxaram" uma sacola que continha drogas e dinheiro. Foi posto na viatura policial. Os policiais disseram que "dariam uma volta e se ele não apontasse os traficantes, seria encaminhado até a delegacia". Falou que tem duas filhas para cuidar. Os milicianos disseram que "apenas queriam os traficantes da vila". Reside no Bairro Fortunato Rocha Lima. Residia no mesmo bairro em que o local dos fatos. Foi abordado por volta das 16h. No momento, caminhava pela via pública. Quando os policiais chegaram, dirigia-se até a residência de sua esposa, para buscar sua filha. Estava em liberdade há três meses. Respondeu a processo por tráfico de drogas. Neste processo, foi abordado por outros policiais. Tem 21 anos. Trabalha no "ferro-velho", na parte da limpeza de materiais. Labora com "Leandro Joaquim" (fls. 138/140).

Tendo em vista o conjunto probatório amalhado nos autos, denota-se que a materialidade e autoria delitiva foram sobejamente comprovadas. Com efeito, os policiais militares Rodrigo e Leandro prestaram depoimentos uníssomos no sentido de que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento, quando avistaram o acusado, na via pública e com "volume na cintura". Com a aproximação da equipe, o acusado demonstrou "nervosismo", o que, somado ao fato de que ele estava na posse de volume da cintura, motivou a abordagem policial. Durante a busca pessoal, os milicianos localizaram, no bolso do acusado, variedades de drogas, tais como "crack", cocaína e maconha e mais numerário. Nesse ínterim, o acusado declarou que promovia o tráfico de drogas, bem como indicou um local próximo a ele. No local indicado, isto é, numa árvore, debaixo de uma pedra, havia uma "sacola" que continha mais 11 porções de maconha e a quantia de R\$ 445,70.

Nessa seara, com todo respeito ao nobre e combativo Defensor Público, não procede a tese de que a abordagem policial fora ilegal. Isso porque, nos termos do art. 244, do CPP, havia "fundadas suspeitas", já que o réu estava em posse de um "volume na cintura", em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, bem como demonstrou mudança de comportamento ao perceber a presença dos policiais. Assim, observa-se

que a abordagem pessoal decorreu de todo um contexto que fundou o convencimento dos agentes públicos no sentido de que o acusado praticava o comércio ilícito, e que chamou a atenção dos policiais. Além disso, não se pode desconsiderar que o réu era reincidente específico, conforme certidão de antecedentes de fls. 51/53, bem como ostentava registros de atos infracionais na Vara da Infância (fls. 54/55). Portanto, abriu-se uma situação objetiva e racional, legitimadora da ação policial, que atendeu o disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar qualquer ilegalidade. Nesse sentido:

“TRÁFICO DE DROGAS RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL NULIDADE INOCORRÊNCIA PRESENTE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO DOS POLICIAIS HIPÓTESE DE FLAGRANTE PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. TRÁFICO DE DROGAS RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INADMISSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS CONDENAÇÃO MANTIDA PENAS E REGIME PRISIONAL CORRETAMENTE FIXADOS RECURSO NÃO PROVIDO. A preliminar não merece acolhida. Com efeito, extrai-se do conjunto probatório, como se verá, que a diligência dos policiais militares de abordagem e revista pessoal da acusada, com consequente prisão em flagrante delito pela posse de drogas ilícitas destinadas à mercancia espúria, ocorreu de modo regular, com esboço em fundada suspeita de prática delituosa, inexistindo, a despeito do entendimento da defesa, qualquer violação ao disposto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Em apertada síntese, consta que a acusada estava sentada em um banco na rodoviária de Presidente Prudente SP, quando, ao perceber a aproximação dos policiais militares, esboçou uma reação estranha e demonstrou nervosismo, o que levantou suspeita. Realizada a abordagem de Jéssica, ela prontamente confessou aos policiais que trazia tabletes de maconha dentro de um travesseiro. Foi solicitado apoio a uma PM feminina, que realizou a busca pessoal na acusada, sendo que nada de ilícito foi encontrado. Contudo, no interior do mencionado travesseiro, havia seis tabletes de maconha, totalizando 6kgs. A inviolabilidade da intimidade da pessoa, norma constitucional de eficácia contida, está insculpida e consagrada no art. 5º, inc. X, da Constituição Federal, dispondo da seguinte maneira: “X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Contudo, ela pode ser mitigada, dentre outras possibilidades, diante da constatação de ocorrência de crime, como in casu. Por sua vez, considerando-se que o tráfico ilícito de drogas é crime permanente, verifica-se permitido pela Carta Magna a ação dos agentes em revistas pessoais de pessoas suspeitas, em locais públicos ou privados, com vistas às providências necessárias e cabíveis para a prisão em flagrante do agente criminoso e consequente apreensão do material ilícito, desde que presente a justa causa. No caso sub judice, conforme já delineado, vê-se presente a justa causa de forma inequívoca, autorizando a realização da revista pessoal diante da inquestionável conduta suspeita da acusada. Nesse sentido: “TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS. EIVA INEXISTENTE. 1. Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. (...)”. (STJ Habeas Corpus nº 552.395-SP, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, j. 20.02.2020). Rejeitada a preliminar, passa-se à análise do mérito” (TJSP - Apelação Criminal com Revisão nº 1500394-32.2020.8.26.0583, Relator(a): Jayme Walmer de Freitas, Comarca: Presidente Prudente, Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 23/11/2022, Data de publicação: 23/11/2022).

“HABEAS CORPUS Artigo 33, da Lei nº 11.343/06 Pleito de nulidade da busca pessoal, pela ausência de fundada suspeita Reconhecimento Impossibilidade Abordagem apoiada em contexto que chamou a atenção dos policiais Ausência de subjetivismo por parte dos agentes públicos Legalidade da busca pessoal Concessão de liberdade provisória - Descabimento Decisão fundamentada Presença dos requisitos autorizadores da

custódia cautelar Gravidade concreta do delito Crime equiparado a hediondo Réu já beneficiado com acordo de não persecução penal, em processo em que também era acusado pela prática do crime de tráfico de drogas. Ordem denegada. Assim, observa-se que a abordagem pessoal decorreu de todo um contexto que fundou o convencimento dos agentes públicos no sentido de que o paciente praticava o comércio ilícito, já que estava em local conhecido pelo comércio ilícito e portava uma sacola, atitudes comuns àqueles que exercem o comércio de entorpecentes, e que chamaram a atenção dos policiais. Portanto, abriu-se uma situação objetiva e racional, legitimadora da ação policial, que atendeu o disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ausência de fundada suspeita. Sobre a questão da busca pessoal, colacionam-se recentes decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PELA PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPP. DOSIMETRIA. AUMENTO DA BASILAR. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS, ALÉM DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Destarte, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado v. aresto reprochado, bem como no auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade policial, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. Ademais, no que tange ao pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude das provas, verifica-se que o v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão pessoal, sob o fundamento de que havia fundada suspeita para a referida diligência porquanto, em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas (cracolândia), os guardas civis visualizaram o acusado em atitude suspeita, uma vez que tentou empreender fuga ao se deparar com a viatura, levando à abordagem que resultou na apreensão de entorpecentes de natureza extremamente deletéria. Precedentes (...)." (HC 742941/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissatto, Quinta Turma, j. 09/08/2022, DJe 16/08/2022). TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA PESSOAL (EM VIA PÚBLICA), VEICULAR E NO INGRESSO DOMICILIAR (SEM ORDEM JUDICIAL). IMPROCEDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO APTO A INDICAR FUNDADA SUSPEITA SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA, APTA A FUNDAR A CONVICÇÃO DOS POLICIAIS DE QUE O AGRAVANTE TRAFICAVA ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 1. A moldura fática delineada nas instâncias ordinárias é de que a busca pessoal efetivada não decorreu exclusivamente de um mero nervosismo do corréu no momento da abordagem, como alegado na impetração, mas de todo um contexto que fundou a convicção dos policiais no sentido de fundada suspeita da prática de crime de tráfico de drogas (grifei), com especial destaque ao fato de que, com o corréu, ao ser interpelado ainda em via pública, foi apreendido com um tijolo de maconha supostamente adquirido do agravante (...)." (AgRg no HC 688825/SP Relator Ministro Sebastião Reis Júnior Sexta Turma j. 17/05/2022, DJe 20/05/2022) Portanto, considerando a regularidade da abordagem pessoal e da apreensão dos entorpecentes, não há que se falar em ausência de prova da materialidade ou em inexistência de indícios de autoria, de rigor o prosseguimento da ação penal." (TJSP - HABEAS CORPUS Nº 2248593-76.2022.8.26.0000, Relator(a): Renato Genzani Filho, Comarca: Franco da Rocha, Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 11/11/2022, Data de publicação: 11/11/2022).

Dessa forma, fica afastada a preliminar aventada pela Douta Defesa.

No mérito, tem-se que ficou comprovada a prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo acusado. Ora, em que pese o acusado, em seu interrogatório judicial, ter negado a mercancia ilícita, sua versão restou isolada do conjunto probatório. Isso porque, conforme os policiais militares, o acusado foi surpreendido na posse de várias espécies de drogas ("crack", cocaína e maconha") e quantia monetária em seu bolso. Além disso, não se pode olvidar que, informalmente, o réu admitiu que estava no local dos fatos e que promovia a venda das drogas. Ademais, próximo ao acusado, os agentes de segurança localizaram uma sacola, que

continha mais 11 porções de maconha e a quantia de R\$ 445,70. Dessa forma, considerando a proximidade que tais objetos estavam do acusado e o contexto em que se deu a abordagem policial, ficou evidenciado que os entorpecentes e a quantia monetária apreendidos nos autos pertenciam ao acusado.

Dessa forma, com todo respeito ao nobre e combativo Defensor Público, as palavras dos policiais militares devem prevalecer sobre a do réu, eis que foram unísonas e corroboradas pelas demais provas produzidas, como auto de exibição e apreensão de fls. 16/17. Ademais, não se pode olvidar que o réu se trata de reincidente específico, bem como, em juízo, confirmou que já fora abordado, em outra ocasião, no mesmo bairro, em posse de drogas, sendo que, no referido processo, a abordagem foi feita por outros policiais. Logo, não há indícios de que as testemunhas tenham alterado a verdade dos fatos, para incriminar o acusado, de forma injusta. Sobre a validade dos depoimentos policiais, em crime de tráfico de drogas, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já se pronunciou:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Condenação mantida. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão do acusado e prova da apreensão dos entorpecentes. Pena. Aumento da base justificado, afastando-se a alegação de bis in idem no aumento de pena na primeira fase e segunda pelas reincidências do acusado. Condenações diversas. Impossibilidade de reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. O acusado é portador de maus antecedentes e reincidente específico. Regime prisional mantido no fechado. APELO DESPROVIDO. Como se vê, diante as palavras dos policiais civis e a apreensão das drogas, resta devidamente caracterizado o narcotráfico, pois o réu fora preso em conhecido ponto de venda do material ilícito e em poder de considerável quantidade de entorpecentes para um mero usuário. Além disso, ele tentou se evadir quando percebeu a aproximação dos policiais e já possui condenação pela prática do mesmo delito. Em relação ao depoimento dos policiais, é importante destacar que seus relatos foram harmônicos, não havendo razão para desprezá-los só porque emanam de funcionários públicos. Ademais, não existe nenhuma notícia ou indício de que eles teriam razão para incriminarem falsamente o réu ou o persegui-lo por traficância. Nem soa crível que os policiais tenham simulado a prisão de inocente pela prática de crime tão grave. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do Colendo STJ: “Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes” (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019). No mais, a ausência de testemunhas civis da prisão do acusado não descredita a versão dos policiais, eis que, no caso de tráfico de drogas, é incomum que terceiros estejam no local, a não ser quando o traficante é surpreendido em atos típicos de venda, o que não foi o que ocorreu neste processo. Registra-se também que as circunstâncias da prisão, a forma de acondicionamento, não deixam margem para dúvida quanto à destinação ao tráfico” (TJSP - Apelação Criminal nº 1511501-03.2022.8.26.0228, Relator(a): Marcos Correa, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 25/11/2022, Data de publicação: 25/11/2022).

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Além disso, os entorpecentes estavam acondicionados em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão. Nessa senda, a forma na qual os entorpecentes foram apreendidos (em porções individuais) e em espécies diversas (“crack”, cocaína e maconha), aliada ao fato de que foi apreendida significativa quantia monetária distribuída em notas diversas permite concluir que o réu realizava o comércio espúrio, na ocasião em que

se deu a abordagem policial.

Outrossim, ao contrário do que entende a douta defesa, a ausência de qualificação de outras pessoas que eventualmente estavam presentes no local dos fatos não tem o condão de ensejar a absolvição do acusado. Ora, é notória a dificuldade fática em identificar eventuais testemunhas civis, em crime de tráfico de drogas, em razão do receio por elas de retaliação por parte de pessoas ligadas à criminalidade. Soma-se, ainda, o fato de que, em locais onde ocorre a prática do crime de tráfico, é cediço a presença de “olheiros”, ou seja, pessoas envolvidas com a traficância e que colaboram com o comércio espúrio. Logo, deve prevalecer a narrativa prestada pelos policiais militares. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DA RÉ LAYLA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E O AFASTAMENTO DA COAUTORIA IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente os réus. Recursos não providos. Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo os apelantes, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoas que sabem ser inocentes. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras deles. Considere-se ainda que em casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela qual desprezar o depoimento policial nesses casos implicaria em consagrar a total impunidade. Frise-se que o conjunto probatório foi uníssono no sentido os acusados estavam juntos, em local conhecido como ponto de venda de drogas, ambos em poder de entorpecentes e de dinheiro, não sendo crível que a ré tenha se apoderado de parte das drogas e a escondido sob o sutiã para depois jogá-la fora, até porque também estava em poder de dinheiro, tudo a evidenciar que os réus estavam agindo juntos, um aderindo à conduta do outro. Assim, a quantidade de drogas apreendidas (16 microtubos plásticos contendo 16,34g de cocaína e 10 microtubos plásticos contendo 11.66g de cocaína), e as circunstâncias em que se deu a prisão (após os acusados se portarem de forma suspeita ao visualizarem a viatura, em via pública, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, tudo isso somado à significativa quantia em dinheiro apreendida e à confissão informal dos réus) evidenciam que, efetivamente, esses entorpecentes se destinavam à entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. Cumpre salientar, por oportuno, que a prova da materialidade do crime em questão não depende, necessariamente, da apreensão de toda a droga em poder do agente, admitindo-se tal prova por outros elementos que conduzam à certeza quanto ao seu envolvimento com substâncias apreendidas com corréus, até porque a figura penal em questão admite coautoria ou participação. Por fim, destaca-se que, mesmo não tendo os policiais presenciado ato de mercancia de entorpecente, tal fato não enseja o afastamento da prática da conduta típica, pois as simples ações de trazer consigo os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Em face de tão sólido conjunto probatório, que é uníssono em incriminar os réus, a condenação foi de rigor, sendo impossível a absolvição” (TJSP - Apelação Criminal nº 1500169-50.2021.8.26.0559, Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda, Comarca: São José do Rio Preto, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 25/11/2022, Data de publicação: 25/11/2022).

Diante desse contexto fático, ficou evidenciado que o numerário apreendido nos autos era oriundo da traficância. Em primeiro lugar porque os policiais militares, em juízo, afirmaram que o réu admitiu a prática do comércio espúrio. Em segundo lugar, não se pode desconsiderar que, em sede policial, o réu declarou que estava desempregado, à época dos fatos, conforme documento de fls. 28. Em juízo, em que pese o acusado tenha alegado que laborava em um “ferro-velho”, não comprovou a mencionada atividade lícita, nos termos do art. 156, do CPP. Sendo assim, é crível

concluir que a quantia monetária apreendida foi decorrente da venda de entorpecentes. Logo, é de rigor a condenação do réu pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Assim, não resta dúvida acerca da procedência da pretensão punitiva, sendo evidente que a conduta do réu se enquadra no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Passo à fixação da pena.

Art. 33, da Lei 11.343/2006

Atenta ao sistema trifásico de fixação da pena, em atenção ao disposto no artigo 68, do CP, na primeira fase, nos termos do artigo 59, do CP, verifica-se que o acusado não registra antecedente criminal, além da reincidência, conforme certidão de fls. 51/53. Contudo, as circunstâncias nas quais o crime foi praticado são desfavoráveis, diante a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado ("crack", cocaína e maconha), bem como a significativa quantia monetária apreendida nos autos, o que evidencia a rentabilidade do comércio espúrio promovido pelo réu. Isso sem falar que, segundo o policial militar Leandro, o réu admitiu, de forma informal, que auferia renda de mil reais por dia com a atividade ilícita. Dessa forma, fixo a pena base elevada em 1/3, ou seja, 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multas.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 51 – Processo 1500410-16.2021.8.26.0594 – fato ocorrido em 19/04/2021). Sendo assim, tendo em vista que a reincidência é específica, majoro a pena em 1/5, de modo que a reprimenda fica em 08 anos de reclusão e pagamento de 799 dias-multas.

Nessa seara, insta apontar que o réu não faz jus ao reconhecimento da menoridade relativa, eis que, à época dos fatos, tinha 21 anos, visto que o crime ocorreu em 13/06/2022 e a sua data de nascimento é 19/10/2000. Veja-se que, consoante a doutrina capitaneada por Rogério Sanches Cunha, para incidir a mencionada atenuante, o agente deve ter menos de 21 anos. Nesse sentido:

A pena deve ser atenuada quando o agente, à época do fato (da ação ou omissão – art. 4º, CP), era menor de 21 anos de idade (menoridade relativa). O legislador penal parte da premissa que a pessoa, antes de completar o 21º aniversário, é imatura, apresentando personalidade em desenvolvimento. De acordo com a maioria, tal premissa foi mantida, mesmo com o advento do Código Civil de 2002 que, no seu art. 5º, anuncia que a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. A opção estampada no Código Civil não revogou a atenuante da menoridade relativa trazida pelo art. 65 do CP, preocupando-se o direito penal com a idade biológica do agente (não considerando sua capacidade civil). Nos termos da Súmula nº 74 do STJ, para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil, o que revela a desnecessidade de identidade ou certidão de nascimento, se existir outro meio idôneo para a comprovação (CUNHA, ROGÉRIO SANCHES, 2020).

Na última fase, justifico a ausência de aplicação da redução de pena nos moldes do artigo art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, porque o acusado não atende aos requisitos dispostos, quais sejam: primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, visto que a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias da prática delitiva, demonstram dedicação à atividade criminosa de comércio ilícito de drogas.

Além disso, a reincidência específica é incompatível com o tráfico privilegiado. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Condenação mantida. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão do acusado e prova da apreensão dos entorpecentes. Pena. Aumento da base justificado, afastando-se a alegação de bis in idem no aumento de pena na primeira fase e segunda pelas reincidências do acusado. Condenações diversas. Impossibilidade de reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. O acusado é portador de maus antecedentes e reincidente específico. Regime prisional mantido no fechado. APELO DESPROVIDO - Importante destacar que não incidiu e não incide, no caso, a causa de diminuição existente no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, o que se mantém, tendo em vista que o acusado é portador de maus antecedentes e reincidente. Com efeito, a redação do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, preceitua que: Art. 33 (...) § 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Como se vê, esta norma possui natureza jurídica de causa especial de diminuição de pena. A finalidade desta minorante é adequar a punição ao caso concreto, atendendo-se ao princípio constitucional de individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal). Seu objetivo é o de adequar a pena prevista no preceito secundário do artigo 33, “caput”, ao fato delituoso que represente menor gravidade, ou seja, reduzida ofensa, menor perigo social, uma vez que se dirige as pessoas que não tenham envolvimento anterior com crimes e que, a despeito de terem praticado uma conduta relacionada ao tráfico de drogas, não se dediquem à traficância, o que não é o caso. Anoto, por fim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que não configura bis in idem a utilização dos maus antecedentes para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC 635.594, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 09.03.2021). Por fim, mantém-se o regime fechado, tendo em vista a pena imposta e a reincidência (específica) comprovada do apelante. Por fim, anote-se que é impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que a sanção fixada é superior a 4 anos (art. 44, I, do CP), o acusado é reincidente e, além disso, a gravidade do crime perpetrado exige punição mais severa, razão pela qual não se mostra social e juridicamente recomendável a pretendida substituição, insuficiente à prevenção e reprovação do delito, à vista do disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal.” (TJSP- Apelação Criminal nº 1511501-03.2022.8.26.0228, Relator(a): Marcos Correa, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 25/11/2022, Data de publicação: 25/11/2022).

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre as situações econômico-financeira favoráveis do réu.

A pena privativa de liberdade do acusado será cumprida em regime inicialmente fechado, diante da quantidade de pena aplicada, da quantidade, natureza e variedade da droga encontrada, da reincidência específica e das condições em que ocorreu o crime, além da necessidade de aplicação do regime adequado para evitar novos comportamentos análogos e visando a ressocialização do réu totalmente imerso no mundo da traficância.

Diante da pena aplicada, insuscetível é a substituição por pena restritiva de direitos e também não se mostra adequado o sursis penal. Ademais, tais benefícios se concedidos ao réu não resultariam na sua ressocialização e nem mesmo seriam eficazes para a expiação da culpa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal, pelo que CONDENO o réu FERNANDO LUIZ PEREIRA, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado e ao pagamento de 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista que o réu respondeu ao processo custodiado, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Nessa senda, destaca-se que os motivos que ensejaram a prisão preventiva do réu ainda permanecem presentes. Além disso, vale ressaltar que a segregação cautelar é medida que se impõe, para assegurar a ordem pública e a paz social, eis que ficou evidenciado que o réu fazia do tráfico seu meio de vida, já que não comprovou o exercício de nenhuma atividade lícita. Nessa linha:

Ementa: 1-) "Habeas Corpus" com pedido liminar. Tráfico de drogas. 2) Pleito para concessão de liberdade provisória. Sentença condenatória denegou o direito ao paciente de recorrer em liberdade. Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da situação fáticojurídica que ensejou o decreto preventivo. O mero reconhecimento da permanência dos motivos ensejaram a prisão preventiva na fase inicial constitui fundamento idôneo para sua manutenção e satisfaz a exigência contida nos arts. 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3-) Ordem denegada (TJSP - Habeas Corpus nº 2269187-14.2022.8.26.000, Relator(a): Tetsuzo Namba, Comarca: Pedregulho, Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 25/11/2022, Data de publicação: 25/11/2022).

No tocante aos objetos apreendidos, autorizo a destruição. Quanto ao numerário, determino a perda em prol da União, nos termos do art. 63, da Lei 11.343/2006, uma vez que ficou comprovada que foi proveniente da prática do crime de tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias, oficie-se à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, e comunique-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade judiciária. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Bauru, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA